

1500454-07.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Angatuba

Foro: Foro de Angatuba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Angatuba

Foro de Angatuba

Vara Única

Rua Públio de Almeida Melo, 832, Angatuba-SP - cep 18240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500454-07.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-07.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2085900/2021 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 17037446 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 1872/21/300 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2085900 - DEL.POL.ANGATUBA, 1872/21/300 - DEL.POL.ANGATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE OLIVEIRA AVILLA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública deflagrada pelo Ministério Público em face de RODRIGO DE OLIVEIRA AVILLA e SILVANA DOS SANTOS, qualificados nos autos, por suposta incursão nas condutas típicas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 35, caput, também da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Segundo a denúncia, desde data incerta, porém antes do dia 28 de março de 2021, em local incerto, nesta cidade e comarca, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º e 34 da Lei nº 11.343/2006.

Consta ainda que no dia 28 de março de 2021, por volta das 22h50min, na Rua

Raimundo Soares Leite, 27, Centro, nesta cidade e comarca, os réus, em concurso, vendiam, traziam consigo ou guardavam drogas, consistentes em 78 (setenta e oito) porções de crack, totalizando 10,87 gramas da droga; 02 (duas) porções de maconha, totalizando 3,48 gramas da droga; e 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 14,39 gramas da droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia (fls. 194/196) foi oferecida e determinou-se a notificação dos acusados, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 198).

Notificados (fls. 212/213), os acusados ofereceram defesas preliminares (fls. 218/219).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 247/249), oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na audiência, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas arroladas e os acusados interrogados (fls. 195/199). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais onde requereu a procedência em parte da ação penal. A defesa dos réus postulou pela absolvição de ambos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 02/05), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07), pelos Autos de Constatação Provisória (fls. 33/35), pelo Laudo de Exame Toxicológico (fls. 121/126 e 187/189) e pela prova oral coligida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada.

Marcos Rogério de Almeida, Policial Militar, disse que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, juntamente com o Sargento Camargo e o Soldado Fogaça, quando uma pessoa, que não quis se identificar, os acionou e informou que na Rua Raimundo Soares Leite, número 27, havia um casal vendendo drogas. A pessoa narrou que o homem permanecia no portão aguardando os “clientes” e, quando chegavam, o homem repassava o “pedido” a mulher que estava dentro da residência, sendo que ela, então, providenciava a droga solicitada. Narrou que “diante dos fatos, a guarnição foi até o local; que no local, avistaram um homem, posteriormente identificado como Rodrigo de Oliveira Ávila, o qual foi revistado e nada de ilícito foi encontrado; que porém, após uma breve entrevista, o homem confirmou a venda de drogas junto com sua esposa, posteriormente identificada como Silva dos Santos; que além disso, confirmou e identificou o local onde as drogas estariam guardadas, ou seja, dentro de um dos quartos, em uma cômoda, acondicionadas em uma sacola plástica, autorizando a entrada da guarnição”. Uma vez dentro do imóvel dos réus, os policiais encontraram a sacola indicada pelo réu, sendo que dentro dela havia 78 pedras de crack, duas porções de maconha e duas porções de cocaína. Além dos entorpecentes foi encontrada a quantia de R\$100,00 (cem reais) em notas diversas. A testemunha alegou que, a princípio, a ré Silvana negou a propriedade dos entorpecentes, mas, posteriormente, acabou confirmando a venda das drogas, tendo, inclusive, informado que vendia cada porção de crack por R\$10,00 (dez reais), narrando, ainda, que iria fracionar a cocaína localizada para vender em porções menores (Fls. 13/14).

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Marcelo Augusto de Camargo, prestado na fase inquisitiva (fls. 15/16).

Ressalte-se que ambas as testemunhas de acusação confirmaram, em juízo, as versões apresentadas em solo policial.

Os depoimentos dos agentes públicos possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e harmônicos, merecendo credibilidade deste juízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL.PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).

A ré SILVANA confessou, durante depoimento prestado na delegacia (fls. 17/18), que a droga encontrada no local dos fatos era sua e, apesar de não saber a quantidade exata, acreditava possuir três pacotes de entorpecentes, contendo 15 (quinze) pedras de crack. Relatou que a maconha era de seu marido, o réu Rodrigo, o qual é usuário de drogas. Afirmou, ainda, que a quantia encontrada, de R\$100,00 (cem reais) era oriunda da venda dos entorpecentes, esclarecendo que costumava vender cada pedra de crack por R\$10,00 (dez reais). Relatou, ainda, que seu marido sabia da venda de drogas, sendo que a auxiliava, chamando-a sempre que chegava alguém querendo adquirir o entorpecente. Por fim, esclareceu que estava vendendo drogas a aproximadamente uma semana, tendo iniciado a atividade pois estava precisando de dinheiro. Durante seu interrogatório em juízo reiterou a confissão, alegando que praticava o tráfico porque estava com dificuldades financeiras e para sustentar o vício de drogas.

RODRIGO, apesar de negar a venda de drogas, afirmou ter ciência da existência dos entorpecentes em sua casa, afirmando que acreditava serem as mesmas de propriedade de sua esposa, porém, não sabia que ela estaria vendendo os entorpecentes. Narrou, ainda, que pessoas costumavam chegar em sua casa e chamar por sua esposa e que notou que, nos últimos dias, a ré Silvana passou a trazer mais dinheiro para a casa, mas não desconfiou que os valores seriam oriundos da venda de droga. Em juízo, o réu confessou a venda das drogas por volta de um mês, alegando que praticava o tráfico porque estava com dificuldades financeiras e para sustentar o vício de drogas.

Em que pese a negativa do réu em sede policial, é certo que sua versão destoa das demais narrativas constantes do presente processo, sendo certo que ambos os policiais ouvidos afirmaram que Rodrigo teria, informalmente, confessado a venda dos entorpecentes juntos com sua esposa.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Portanto, em que pese o esforço empreendido pela combativa defesa, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como os depoimentos dos policiais, são circunstâncias que caracterizam a traficância, conforme o artigo o art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Cabe mencionar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do acusado logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do acusado sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

No presente caso, tenho que restou suficientemente comprovado nos autos que os acusados se davam a prática do crime de tráfico de drogas, havendo confissão de ambos em juízo.

Com efeito, as testemunhas relataram que foram até a residência dos réus após receberem uma denúncia anônima de que havia venda de entorpecentes no local, sendo que o denunciante informou que o Réu Rodrigo ficava na frente da casa recebendo os pedidos dos usuários que lá chegavam, enquanto a Ré Silvana ficava dentro da residência separando as drogas e entregando-as ao seu esposo para que ele repassasse aos "clientes". Ao chegarem no local, os policiais encontraram Rodrigo, de fato, na frente da residência, estando a Ré dentro da casa, e, dentro do imóvel foram encontradas as drogas, levando a crer que a venda ocorria da exata maneira relatada pela denúncia.

Ademais, além dos entorpecentes, foram localizados com os réus diversos materiais utilizados para o acondicionamento e venda de drogas, tais quais, papel alumínio, sacos plásticos, entre outros, além do dinheiro encontrado em posse dos réus. Fatos estes que denotam a intenção de mercancia dos entorpecentes pelos réus.

Por outro lado, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, exige-se que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado, sendo as vontades, portanto, distintas.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências, trazidas por Renato Marcão em sua obra *Tóxicos* (São Paulo: Saraiva, 6ª. ed., 2009, p. 256 e 260):

"O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado" [TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câmara, j. 6-4-2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571].

"Configura-se com o animus associativo, isto é, um ajuste prévio, no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdade, em que a vontade de se associar sobrepaire, mas coexista com a vontade necessária à prática do crime visado" [TJSP, Ap. Crim. 210.425-3/7, 4ª Câmara, j. 10-6-1997, rel. Des. Bittencourt Rodrigues, RT 745/539].

"Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada" [STF, ROHC 75.236-5/AM, 1ª T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º-8-1997, RT 749/584]" (*Tóxicos*, São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2009, p. 256 e 260).

Na mesma linha, leciona Damásio de Jesus: "Elementos subjetivos do tipo O primeiro é o dolo, vontade consciente de concretizar a associação. Há um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão 'para o fim de praticar' [crimes dos arts. 33, caput e § 1º, 34 e 36 desta Lei]. Sem a finalidade especial o fato é atípico. Nesse sentido: RT 532:381. Assim, a figura típica exige a presença do ânimo associativo, i. e., 'de um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado' [Vicente Greco Filho, *Tóxicos*, cit., 1979, p 104]" (Lei Antidrogas Anotada, São Paulo: Saraiva, 9ª ed., revista e atualizada, 2009, p. 160).

A elementar "reiteradamente ou não", prevista no art. 35, "caput", não tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar "associarem-se"), caracteriza mero concurso de agentes (CP, art. 29, "caput") destinado à realização de um dos crimes previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º e 34, ambos de tal Lei, hipótese em que somente um destes (delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34) se consuma; e, para a caracterização da infração penal de associação para o tráfico, exige-se, consoante já exposto, um dolo distinto, separado do cometimento em si do tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que não haja reiteração de conduta, sendo este o significado da primeira elementar ora mencionada ("reiteradamente ou não").

São situações distintas, portanto, sendo o ato de se associar para o tráfico, o

qual exige prova concreta (separada), uma coisa, e o de praticar efetivamente o tráfico ilícito, outra; caso dois ou mais agentes, por exemplo, atuem em conjunto para vender drogas, sem a constituição de uma associação destinada ao comércio ilícito, ocorre mero concurso de agentes para o cometimento do crime previsto no art. 33, "caput", e, na hipótese de além de a venda em si da substância ilícita, eles estabelecerem um vínculo associativo, organizado, distinto, destinado às vendas, a conduta criminosa descrita no art. 35, "caput", também se caracteriza. Aliás, sendo o momento consumativo do crime de associação para o tráfico a ocasião em que os agentes se associam para a prática dos delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34, ambos de tal Lei (conforme lição de Damásio de Jesus sobredita), o crime previsto no art. 35, "caput", do mesmo Diploma Legal, pode ocorrer sem que o agente pratique efetivamente os crimes descritos nos dispositivos de lei supramencionados (arts. 33, "caput" e § 1º, e 34).

Quanto ao momento consumativo do crime, ensina Damásio de Jesus: "Momento consumativo Ocorre com a associação. Na expressão de Italo Galli, no 'momento associativo' [JTACrimSP, 54:351]. Nesse sentido: RT, 634:277; RJTJSP, 72:316; STJ, REsp 3.943, 5ª. Turma, DJU, 5 nov. 1990, p. 12437, independentemente de eventual prática dos crimes pretendidos pelo bando. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348. Sob esse aspecto, trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, natureza extraída do elemento subjetivo do tipo 'para o fim de...'. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348" (op. cit., p. 161/2).

Ainda, tenho que, para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, são necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo (associativo) entre os agentes, tais como interceptações telefônicas anteriores ou em andamento, pedidos de busca e apreensão anterior, realizações de campanhas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação comprobatória e até mesmo apreensão, em data anterior, de drogas pertencentes aos investigados, não bastando, desse modo, meras informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes vinham praticando a mercancia ilícita. Ademais a doutrina e a jurisprudência, quase que de forma unânime, exigem a comprovação de dois requisitos para a caracterização de delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, sendo eles estabilidade e permanência, os quais não ficaram comprovados na conduta dos acusados.

Sobre a necessidade de prova de tais requisitos (estabilidade e permanência) na espécie, segue o posicionamento da jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo Precedentes Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g). Materialidade e autoria bem demonstradas. Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa Desclassificação para uso pessoal. Impossibilidade Finalidade mercantil Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto Regime fechado Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES- RÉUS QUE TRANSPORTAVAM E GUARDAVAM 11 PORÇÕES DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA- CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO, PREPARO OUTRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES CONDUTAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS OBJETOS APREENHIDOS QUE SE DESTINAVAM À SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS TÓXICOS ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA O RÉU NIVALDO POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP- APL:30038922720138260286SP3003892-27.2013.8.26.0286,

Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 29/10/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2015).

Ainda nesse prisma: "O crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas. No caso, tendo as instâncias ordinárias, após exame das provas dos autos, constatado a existência de estabilidade e permanência entre o agravante e outros indivíduos, inviável a reversão do julgado ante o óbice constante da Súmula 7/STJ." [AgRg no AREsp 303.213/SP, 5.ª T, rel.

Marco Aurélio Bellizze, DJ 08.10.2013).

No presente caso, não restou devidamente demonstrado que a associação entre eles era estável e duradoura, sendo que a própria ré, em seu depoimento em solo policial, afirmou que estava vendendo os entorpecentes somente a uma semana, enquanto que o réu declara que traficavam a um mês. Ademais, não restou suficientemente comprovado o vínculo associativo, minimamente organizado, distinto, destinado às vendas, a conduta criminosa descrita no art. 35, "caput" da Lei de Drogas.

Assim, não havendo prova suficiente para a condenação, a absolvição é de rigor. Diante de todo o exposto, comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11. 343/06, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que os Acusados não possuem maus antecedentes e que as demais circunstâncias lhes são favoráveis ou neutras. Portanto, fixo a pena-base no mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, por isto, a pena intermediária deve ser mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Entendo presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista a primariedade dos agentes, não haver condenações transitadas em julgado ou outros elementos que provem serem os autores integrantes de facção criminosa ou que se dediquem a atividades criminosas. Portanto, não há motivos que impeçam a redução no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Logo, fixa-se a reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tendo em vista a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90, ou seja, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado, assim incidentalmente declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal, porquanto "a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena" (STF, Habeas Corpus nº. 27/06/2012, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27/06/2012), a quantidade da pena corporal imposta, a primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçosa a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Outrossim, é de se observar que o Pretório Excelso, no recente julgamento do HC nº. 118.533/MS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 23/06/2016), firmou o entendimento de que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos"; logo, "O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo como organização criminosa". De seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça "a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da

proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça" (Petnº. 11796/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em23/11/2016), aderiu à tese fixada pela Suprema Corte e cancelou o enunciado nº.512 de sua súmula.

No presente caso, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, haja vista que os denunciados preenchem os requisitos previstos nos incisos do artigo 44 do Código Penal, ou seja, a pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos, o crime ao qual foram condenados não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, os réus não são reincidentes em crime doloso e as circunstância judiciais são a eles favoráveis, de forma a indicar ser essa substituição suficiente para reprovação e prevenção do delito. Restando a pena definitiva em patamar superior a 1 (um) ano, substituo a pena corporal por: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em atividade compatível com a aptidão pessoal dos réus, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada no curso da execução do título judicial, e b) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, ex vi dos artigos 43, caput, incisos I e IV, e parágrafo 2º, in fine, 45, parágrafo 1º, e 46, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR os réus RODRIGO DE OLIVEIRA AVILLA e SILVANA DOS SANTOS como incurso nos crimes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, regime inicial ABERTO, observando-se a substituição deferida, e ABSOLVÊ-LOS da imputação do artigo 35, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Os acusados poderão apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à sociedade, suas utilizações para a prática e produto de crime, nos termos da fundamentação desta sentença.

Arbitro os honorários do(s) defensor(es) nomeado(s) no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Angatuba, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA